MPF 491209 – DEN 656988 caratulado " JUAN ERNESTO ROZAS, CECILIA MARTHA AMIL MARTÍN, EDUARDO JAVIER RIGGI, ANIBAL OSCAR BRUNET y WALTER HORACIO FERNANDEZ S/Art. 249".

1. Llega este caso a conocimiento del suscripto en virtud de la solicitud de revisión de archivo presentada por el Sr. Nicolás H. Kosciuk el 13 de agosto de 2020.

Las actuaciones se iniciaron el día 7 de agosto de 2020, a raíz de la denuncia formulada por el nombrado mediante correo electrónico ante la OCRD de este MPF. En tal oportunidad manifestó: *"(...) quería denunciar que en ninguna de las 6 intervenciones de Fiscales, se me ha permitido presentar pruebas, lo que no es muy raro ya que se encubren entre ellos. Denunciados: Fiscalía 20 -> Fiscal de Cámara de la 20 Fiscalía 29 -> Fiscal de Cámara de la 29 UIT Norte -> Fiscal de Cámara de la Norte (...) Los derechos que invoco están en la LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS - Ley 27372, en concreto el Articulo 5, donde además de no haber aceptado (o rechazado) pruebas, las han ignorado, han resuelto sin avisar (menos intentar averiguar los sucesos), han archivado sin avisar cuando era querellante y encima se citan entre ellos en las resoluciones, cuando el anterior no podría haber tomado una resolución mejor si hubiese tenido pruebas".*

Con posterioridad aclaró: *"[q]uiero denunciar a los fiscales que actuaron mal. A Juan Ernesto Rozas fiscalia Fiscalía PCyF Nº 20- UFO, por la causa MPF 4629272. A Cecilia Martha Amil Martin UFN - Unidad Coordinadora, que investigaba a Rozas, tengo correos envíados a la fiscalía dónde no me respondían. También a Eduardo Riggi UFN, Fiscal de Cámara Norte, por la remisión de la UFN por la DEN64184 y por último a Anibal Oscar Brunet Fiscalia 29, por la DEN649606. Y al fiscal de Cámara de Brunet, creo que es Walter Horacio, ya que hoy me llegó la resolución de archivo de la DEN649606. Tengo para presentar dicha resolución por medio digital ya que está en PDF. La principal causa es que no se hayan echo pericias sobre el cuerpo de mi madre, yo creo que no qusieron manipularlo. El 02 de mayo entre y ví que estaba vacía la unidad donde estaba internada ella, Unidad 1, clínica médica Pabellón 2, Htal. Piñero. Esta denuncia primera que hice es la MPF00462972 donde creo que se hicieron varias cosas mal. Tengo varios documentación para comprobarlo, audios, videos y documentos digitales".*

Posteriormente, el nombrado envió algunos correos electrónicos al personal de la UIT de la UFE, en los cuales refirió: *"primero que nada me gustaria saber si uno se puede presentar personalmente, ya que en mis denuncias anteriores, el envio de emails no ha tenido resultado alguno. Ademas, siendo que el historial de archivos es muy desfavorable y sospechoso, me gustaria que deriven la denuncia al Defensor Publico de Victimas para*

que pueda tomar intervencion Nacion y se me pueda asignar un abogado. Porque creo que la instancia de Ciudad investigando a Ciudad ya cumplio su ciclo. Por lo pronto me gustaria saber como hacer para presentar pruebas y que sean adjuntadas a la denuncia. Ya que por ejemplo todas las fiscalias anteriores aprobaron el intento de Rozas de hacer un allanamiento, y ese allanamiento no tenia ningun sentido y es parte del "armado" de la investigacion. Gracias. (...) Una cosa más, a mi no me interesa tanto demostrar que fue una causa armada para inculpar a todos los fiscales que denuncio, solamente lo necesario para que se pueda hacer una nueva investigacion por el tema de mi madre. Como detalles "divertidos" podria mencionar: Ley de Victimas Art 5. b) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento; Deje el cuerpo de mi madre en el hospital para que pueda hacer las pericias, no solo no hizo ninguna pericia sino que dejo que el cuerpo vaya a tierra. Si ya tenia decidido que iba a ignorar todo lo que pueda aportar el cuerpo o una autopsia, podria haberme avisado para que pueda despedirme y verla por última vez, desde que me echaron no la pude volver a ver. Por ejemplo en el Hospital, a las personas con familiares con pronostico "ominoso" se les permitia ingresar como excepcion. Donde esta la humanidad de un fiscal? Ingenuamente deje el cuerpo a disposicion del Fiscal, no la vi desde el 25/3 (fallecio un mes despues) no se si esta muerta o viva, Rozas se parece a Videla: https://www.youtube.com/watch?v=ASMPYg0YueU Art 5. d) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes; Tenia derecho yo a pedir que la pesen? Es decir, es un abuso pedir eso? Ahora que archivaron la causa me dicen que puedo seguir por via privada, con que pruebas? Si dejaron pudrir el cuerpo. Y el COVID? Se puede detectar despues de tanto tiempo? No solo ignoraron pruebas, sino que ademas perdieron pruebas cruciales. Ahora si, Gracias!".

El 11 de agosto de 2020, el Sr. Fiscal Coordinador de la UIT de la UFE dispuso el archivo del caso en los términos del art. 199, inc. "a" del CPP, en sustento de lo cual –en síntesis- sostuvo: *" el denunciante expone su discrepancia sobre la forma y los tiempos relacionados con la investigación inicial por abandono de persona que habría culminado con el fallecimiento de su madre, y las sucesivas investigaciones en relación a la labor de los Fiscales de Primera Instancia y los Fiscales de Cámara respectivos. Así pues, tal como manifiesta el propio denunciante, su interés radica en que se pueda hacer una nueva investigación por el fallecimiento de su madre. En ese sentido, mediante una seguidilla de denuncias KOSCIUK continúa planteando su oposición y disconformidad con lo dispuesto en el caso MPF 462972 y con la investigación realizada en ese caso, lo que ya fue analizado por otras Fiscalías y en dos instancias, conforme el detalle supra efectuado. No se advierte en ninguno de los casos una conducta ilícita –activa u omisiva- por parte de los Fiscales denunciados, que pueda ser calificada en los términos del art. 249 del CP"* .

Notificado de dicho temperamento el 13 de agosto de este año, el Sr. Kosciuk peticionó, ese mismo día, su revisión. En dicha ocasión sostuvo: " *solicito una revisión simbólica, porque nuevamente resolvieron sin dejarme presentar pruebas..."* y *"[m]e gustaría que en la revisión del (de la) Fiscal de Cámara, se mencione que ninguno de los fiscales quiso aceptar el video https://youtu.be/jzmWhk7Fs-Y, donde se comprueba el falso testimonio del médico (tan bien investigan que no nadie se dio cuenta que mentía, nadie miente tanto*

sin impunidad asegurada) y una coordinación con MPF - Hospital para obtener esos dichos (en eso usaron los días entre denuncia e intento de allanamiento), haber aceptado una historia clínica manipulada por ese médico y la pérdida de pruebas, porque instancia privada o no, ya no se sabe ni se puede saber cuánto pesaba al fallecer ni si murió de covid...". Luego, envió otro correo en el que se lee: *"[p]erdon, pero me olvidaba lo mas obvio: 'En concordancia con el resto de sus colegas, la UIT Este a cargo de la DEN656988 resolvió sin interesarse siquiera de las supuestas pruebas que decía tener el denunciante, lo que parece ser el modus operandi en el MPF' Listo, con eso ya lo podria imprimir y enmarcar :D Que tengan lindo dia".*

2 .- En estas condiciones, como primer punto debo señalar que la oposición al archivo dispuesto fue presentada en tiempo oportuno, por lo que corresponde proceder a su análisis.

En lo que hace al fondo de la cuestión traída a mi conocimiento, adelanto que comparto el temperamento adoptado por mi colega de grado y, por las razones que expondré a continuación, confirmaré el archivo del caso.

En primer lugar, enumeraré brevemente las denuncias a las que hizo referencia el Sr. Kosciuk, así como también los fiscales que intervinieron en ellas y las resoluciones a las que arribaron.

En tal sentido, del sistema informático Kiwi se desprende que el caso MPF 462972, caratulado *"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PIÑERO y otros s/infr. Art(s). 106 Párr. 3º y 248 CP"* –bajo el cual fueron acumuladas las denuncias DEN632469, DEN641871 y DEN641877– tramitó ante la Fiscalía PCyF N° 20, a cargo del Dr. Juan Ernesto Rozas, quien dispuso su archivo en los términos del art. 199 inciso "a" del CPPCABA, el cual fue convalidado por el Fiscal de Cámara de la UFO, Dr. Sergio Martín Lapadú.

Asimismo, el caso MPF 479852 (DEN 641840) caratulado *"s/nombre s/Art. 249",* originado como consecuencia de la denuncia efectuada por el nombrado contra el Dr. Rozas en virtud de su labor en el caso anteriormente citado, tramitó ante la UIT de la UFN, cuya titular, la Dra. Cecilia Martha Amil Martín, dispuso el archivo en los términos del art. 199 inc. "a" del CPPCABA. Dicha decisión, a su vez, fue convalidada por el Fiscal de Cámara de la UFN, Dr. Eduardo Javier Riggi.

Posteriormente, el Sr. Kosciuk efectuó dos nuevas denuncias (DEN646344 y DEN649606) las cuales fueron acumuladas bajo el número de caso MPF 479255, caratulado *"Unidad Fiscal Norte s/ inf. art. 249 del C.P".* En tal oportunidad, denunció a la Fiscal Coordinadora de la UFN, Cecilia Martha Amil Martín, por *"encubrir"* al Dr. Rozas al resolver el archivo de la denuncia que el nombrado efectuara contra este último por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. En esa ocasión, intervino el titular de la Fiscalía PCyF N° 29, Dr. Aníbal Brunet, quien

resolvió archivar las actuaciones de conformidad con lo previsto en el citado art. 199, inc. a, CPP. Seguidamente, el Fiscal de Cámara de la UFS, Dr. Walter Horacio Fernández, confirmó tal temperamento.

Finalmente, el nombrado efectuó la presente denuncia, mediante la cual, conforme fuera visto, acusó a todos los fiscales anteriormente mencionados por su intervención en los casos aludidos.

Pues bien, sentado ello, me referiré en primer orden a las manifestaciones efectuadas por el denunciante en cuanto a que " *La principal causa es que no se hayan hecho pericias sobre el cuerpo de mi madre, yo creo que no quisieron manipularlo"* y *"(...) a mí no me interesa tanto demostrar que fue una causa armada para inculpar a todos los fiscales que denuncio, solamente lo necesario para que se pueda hacer una nueva investigación por el tema de mi madre (...)".* Resulta evidente que dichas expresiones aluden a las denuncias que el Sr. Kosciuk efectuó en primer término, las cuales dieron origen al caso MPF 462972, en el que –en cuanto aquí interesa- se investigó la presunta comisión del delito de abandono de persona agravado por haber acontecido la muerte de la madre del nombrado. Ahora bien, conforme fuera señalado anteriormente, el caso de mención fue archivado por el titular de la Fiscalía PCyF N° 20 en los términos del art. 199 inc. "a" del CPPCABA, es decir, por atipicidad, temperamento que fue posteriormente convalidado por el Fiscal de Cámara de la UFO. Es por esa razón que el Ministerio Público Fiscal no puede promover nuevamente la acción por el hecho que allí se investigó, como pretende el denunciante, ya que conforme las previsiones del art. 203 del CPPCABA, dicha decisión –archivo por atipicidad– resulta definitiva. Es por ello que me veo imposibilitado de expedirme acerca de las consideraciones efectuadas por el nombrado a su respecto. Sin embargo, el damnificado, al encontrarse constituido en parte querellante, puede continuar con el ejercicio de la acción bajo las formalidades de la acción privada (art. 10 del CPP), como le fuera indicado oportunamente por mis colegas.

Estas mismas consideraciones resultan aplicables a las acusaciones efectuadas por el nombrado contra el Dr. Rozas. Nótese que el desempeño de este último en el caso MPF 462972, ya fue investigado por la Dra. Cecilia Martha Amil Martín en el marco del caso MPF 479852 (DEN 641840), quien dispuso el archivo del legajo por atipicidad. Dicha decisión, a su vez, fue convalidada por el Fiscal de Cámara de la UFN, Dr. Eduardo Javier Riggi, por lo que al resultar definitiva, este Ministerio Público Fiscal no puede reabrir la investigación.

Lo mismo ocurre con la denuncia efectuada contra la Dra. Cecilia Amil Martín, quien según el Sr. Kosciuk, habría incumplido con sus deberes de funcionaria pública al *"encubrir"* al Dr. Rozas. En tal sentido, es preciso recordar que ese caso –MPF 479255– tramitó ante la fiscalía a cargo del Dr. Brunet, quien ordenó su archivo en los términos del citado art. 199, inc. "a", del CPPCABA.

Tal temperamento fue confirmado por el Fiscal de Cámara de la UFS, Dr. Walter Horacio Fernández, otorgando así fin al caso de forma definitiva para este Ministerio Público Fiscal.

En virtud de lo expuesto, aun pese a las particularidades que tiene este caso, en tanto tal como sostiene mi colega de grado lo cierto es que *" mediante una seguidilla de denuncias KOSCIUK continúa planteando su oposición y disconformidad con lo dispuesto en el caso MPF 462972 y con la investigación realizada en ese caso, lo que ya fue analizado por otras Fiscalías y en dos instancias..."* , habré de analizar únicamente si los fiscales Riggi, Brunet y Fernández incurrieron en algún incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos en los casos en los que les tocó intervenir. Esto así, ciñéndome estrictamente a los dichos del denunciante, y en las muy especiales circunstancias del caso, en el que todo parecería indicar que, en definitiva, el Sr. Kosciuk no hace más que expresar su desacuerdo en relación a las decisiones conclusivas adoptadas y sus ratificaciones por parte de los fiscales de cámara intervinientes.

Al respecto, conforme fuera adelantado, coincido con lo resuelto por el titular de la UIT de la UFE. En efecto, si bien corresponde ser extremadamente cauteloso a la hora de descartar la tipicidad de un hecho, los comportamientos atribuidos a los nombrados no reúnen las condiciones necesarias para ser encuadrados en un tipo penal.

Cabe recordar que el art. 248 del CP sanciona al funcionario público que *"dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere"*, mientras que el art. 249 del CP reprime a aquel que *"ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio"*.

En relación con el bien jurídico cuya afectación pretende capturarse en esas figuras, se ha afirmado que es el *"normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado"* (D'ALESSIO, Andrés José (dir.) y DIVITO, Mauro A., (coord.), *Código Penal – Comentado y anotado*, La ley, Buenos Aires, 2004, p. 764), así como que se trata de infracciones que *"afectan la administración pública porque implican en sí mismas un arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las prescripciones constitucionales, de las leyes o deberes que la rigen"* (BUOMPADRE, Jorge E., comentario a los arts. 248/253 *ter* del CP en BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio Raúl (dir.), TERRAGNI, Marco A. (coord..) y DE LANGHE, Marcela (superv.), *Código Penal y normas complementarias – Análisis doctrinal y jurisprudencial*, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, p. 365).

Asimismo, los tipos previstos en los arts. 248 y 249 del CP podrían comprender —entre otras cosas y en lo que aquí nos interesa— la situación de un funcionario que ejerce una autoridad que no le fue concedida por la ley, o que sí le fue adjudicada, pero que es desarrollada arbitrariamente, o bien que omite deliberadamente un deber a su cargo y que, paralelamente, cualquiera fuere el caso, lo hace con *dolo directo*, de manera tal que exhiba una voluntad dirigida a la

violación de la ley y de las funciones a su cargo (véanse, al respecto, D'ALESSIO y DIVITO, ob. cit., pp. 796/804 y BUOMPADRE en BAIGÚN, ZAFFARONI, TERRAGNI y DE LANGHE, ob. cit., pp. 367/373).

Ahora bien, en el ámbito de la tramitación de los procesos judiciales, la eventual existencia de errores en la valoración de las circunstancias del caso o la interpretación de la ley aplicable por parte de los funcionarios actuantes —ya sea fiscales, defensores o jueces—, constituye una situación regularmente prevista por la legislación. De hecho, existen mecanismos expresamente previstos en las normas procesales para advertir y revertir esa clase de eventualidades. Entre ellos se encuentran, solo por mencionar algunos, los recursos (arts. 267 y sgtes., CPP), la nulidad de los actos procesales (arts. 71 y sgtes., CPP) y la facultad de los damnificados de solicitar la revisión de los archivos de las investigaciones (arts. 199 a 203, CPP).

Es claro, entonces, que no cualquier error en el ejercicio de funciones judiciales, defensivas o instructoras implica un incumplimiento encuadrable en los arts. 248 o 249 del CP. De otro modo, ello ocurriría cada vez que una resolución judicial es revocada, un acto procesal es anulado o un archivo es revertido por un magistrado. Es evidente que esta no pudo ser la intención del legislador al regular los mencionados tipos penales. Las figuras penales se refieren, en cambio, a situaciones excepcionales en las que, en rigor, no se trata de meros errores o equivocaciones, sino de actos dirigidos específicamente a la violación de la ley.

Teniendo en cuenta esos parámetros, podemos comenzar por descartar que los fiscales denunciados hayan ejercido una facultad *no concedida por la ley*. El Código Procesal Penal de la CABA autoriza expresamente a los acusadores públicos a ordenar el archivo de las actuaciones en casos penales (art. 199 y ccdtes., CPP) y ello se condice con el diseño acusatorio del proceso penal local, en el que el ejercicio de la acción y la conducción de la investigación preliminar se encuentran a cargo del Ministerio Público Fiscal (arts. 13.3, CCABA y 4, CPP). Paralelamente, se trata de una prerrogativa considerablemente amplia, pues las razones por las cuales la ley procesal autoriza a un fiscal a clausurar una pesquisa son variadas y, en muchos casos, su pronunciamiento puede resultar definitivo respecto de la posibilidad del Ministerio Público Fiscal de continuar impulsando la acción.

Además, la ley procesal no condiciona la *validez* del archivo del caso a la celebración de una entrevista con el denunciante o la producción de prueba, ya que, de hecho, autoriza el archivo *"de la denuncia"* misma (art. 199, CPP). En otras palabras, al margen de la excepcionalidad de las situaciones en las que toda la información necesaria para resolver emerge de ese acto inicial, la ley procesal no prohíbe el archivo de un caso en esas condiciones.

Entonces, dado que el archivo de una denuncia es una posibilidad específicamente prevista por la ley, cabe analizar si ésta fue implementada arbitrariamente o por fuera de los

parámetros establecidos por las normas aplicables.

Al respecto, nótese primero que las decisiones de archivo se fundaron en una causal expresamente prevista en la ley, pues ésta autoriza el archivo cuando *"[a] criterio del Ministerio Público Fiscal el hecho resulte atípico"* (art. 199, inc. a, CPP).

En segundo lugar, los fiscales, en las distintas instancias, *expresaron los motivos* por los cuales consideraban que correspondía clausurar el caso y, al margen de su acierto o error, ellos se relacionan con la causal legal indicada sin que pueda catalogárselos como ilegítimos o ilícitos.

En otras palabras, aun si nos encontrásemos —eventual e hipotéticamente— ante la existencia de alguna clase de insuficiencia en la actividad instructora desplegada o de equivocación en la clausura del caso —p. ej. su carácter prematuro—, esto no podría alcanzar, en modo alguno, para encuadrar la conducta de la acusadora en los tipos penales en cuestión, pues, como vimos, la discusión sobre esa clase de actuación procesal defectuosa discurre por las vías impugnativas *normales* de un proceso.

Finalmente, aunque se soslayara lo expresado hasta aquí, tampoco sería viable afirmar que los comportamientos atribuidos a los fiscales denunciados resultaran típicos en su faz *subjetiva* . Es que, en el peor de los casos, lo que se les atribuiría es no haber obrado diligentemente en el ejercicio de la facultad de archivar un caso o haber aplicado, culposamente, un criterio errado para ello —p. ej. porque, según el entendimiento del denunciante, hubiere correspondido la previa producción de alguna evidencia— y estas conductas difieren sustancialmente del *dolo directo* que exigen las figuras en trato.

Por último, los archivos dictados no privaron definitivamente de algún derecho al denunciante, sino que, por el contrario, le permitieron el ejercicio de la facultad que, en su condición de *denunciante*, le es concedida por la ley procesal, esto es, la solicitud de la revisión de esas decisiones conclusivas.

Lo afirmado hasta aquí no importa, en modo alguno, soslayar las molestias que las situaciones tal como fueron denunciadas pudieron haber generado en el denunciante, pero lo cierto es que aquellas no reúnen las condiciones necesarias para ser abordadas desde una perspectiva penal.

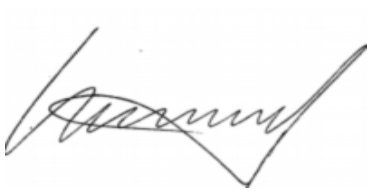
Por último, cabe hacer saber al nombrado que cuenta con la posibilidad de constituirse como parte querellante con el objeto de continuar de manera autónoma con el ejercicio de la acción ante el juez, bajo las formalidades de la acción privada (art. 10, CPP).

En orden a lo expuesto , atendiendo a las constancias digitales del caso obrantes en el sistema informático *"Kiwi"* (cf. arts. 12, 13 y 14 de la Res. FG nro. 76/2013 y resoluciones subsiguientes) entiendo que corresponde:

NO ACEPTAR LA OPOSICIÓN planteada por el Sr. Kosciuk y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el archivo dispuesto por la UIT de la UFE.

Regístrese y notifíquese al denunciante.

Registro nro. 586/RA/FCEste/2020.



GABRIEL ESTEBAN UNREIN
FISCAL DE CAMARA
gunrein@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
14/12/2020 10:48:13